

N. R.G. 4685/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marina Marchetti	Presidente rel.
dr. Francesco Distefano	Consigliere
dr. Francesca Mammone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in VIA VIA G. MAZZINI, 68 20013 MAGENTA presso lo studio dell'avv. NAVA MARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*)

APPELLATO CONTUMACE

avente ad oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole sulle seguenti conclusioni.

Per **Parte_1**

“In via principale –

- accertare e dichiarare la simulazione soggettiva ovvero la intestazione fiduciaria alla sig.ra [...]

Parte_2 *relativamente alla compravendita immobiliare stipulata in Milano il 27-10.2003 tra le sig.re **Controparte_2** e **Parte_2**, a rogito notaio **Persona_1** rep. 34.278 e reg. il 3/11/2003 ed avente ad oggetto l'appartamento sito in Milano via Debussy n. 10 costituito da un appartamento al piano primo, interno 4, composto di tre vani utili, oltre accessori con annesso vano cantina, censito a Catasto Urbano al foglio 376, mappale 330 subalterno 5, Milano via Claudio Debussy n. 10, Piani 1-S1, Z.C. 2, Cat. A/3, vani 5,5, R.C. euro 639,12. Coerenze dell'appartamento: muri perimetrali, int. 5, vano scala, int. 3; e della cantina: corridoio d'accesso, cantina n5, muro perimetrale, cantina n.3; - per l'effetto dichiarare, in virtù di detta simulazione soggettiva ovvero intestazione fiduciaria, l'attore effettivo ed esclusivo proprietario dell'immobile suddetto ordinando all' **Organizzazione_1** di Milano (già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano) la trascrizione dell'emananda sentenza e ogni conseguente trascrizione e volturazione a favore del sig. **Parte_1** **CodiceFiscale_3**) nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 22.9.1949, residente in Milano via Debussy n. 10 e contro la sig.ra [...]*

Parte_2 (**CodiceFiscale_4**) nata a Milano il 3.4.1949, residente in Milano via Debussy n. 10, con esonero da qualsivoglia responsabilità.

in via subordinata e/o alternativa - condannare a norma dell'art. 219 e 2041 c.c. la convenuta

Parte_2 *al pagamento a favore del sig. **Parte_1** di euro 220.743,78 o di quell'altra somma che risulterà acclarata nel corso nel presente giudizio, ad istruttoria compiuta, oltre alle rate maturate da luglio 2015 ed agli interessi di legge dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, quale restituzione dovuta di somme prelevate dal patrimonio personale esclusivo dell'attore a pagamento delle rate del mutuo n. 08/61762462 **Org_2**, per l'acquisto dell'appartamento sito in Milano, via Debussy n. 10 acquistato e intestato alla convenuta in regime di separazione dei beni.*

*in ogni caso – confermare il rigetto delle domande della sig.ra **Parte_2***

*[...] nei confronti dell'Ing. **Parte_1**, compresa quella di compensazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.*

- emettere ordinanza di ingiunzione per le somme non contestate ex art. 186 bis e 186 ter nei confronti della sig.ra Parte_2 per il pagamento di euro 133.404,42 o di quell'altra somma dovuta al sig. Parte_1 ex art. 219 e 2041 c.c.

Spese diritti ed onorari di causa rifiutati.

Si chiede l'ammissione delle prove dedotte in atti e segnatamente di prova orale per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:

1) vero che i coniugi Pt_2 e Pt_1, prima della separazione e dei dissidi familiari avvenuti nell'anno 2012, avevano deciso di dare un appartamento a ciascuno dei due figli Per_2 e Per_3 [...];

2) vero che nell'anno 2003, si profilò l'opportunità di acquistare l'appartamento per cui è causa, fg. 376 mapp 330 sub 5 sempre nello stesso stabile di via Debussy 10 in Milano e sullo stesso pianerottolo;

3) vero che si decise di non intestarlo al figlio Per_3 perché nello stesso periodo era in vendita l'appartamento di proprietà dell'avv. Controparte_3 – fg 376 mapp 330 sub 6 - che si trovava a fianco di quello per cui è causa;

4) vero che l'appartamento dell'avv. CP_3 avrebbe dovuto essere intestato al figlio Per_3 – per ragioni di equità rispetto alla sorella con i mezzi propri del sig. Pt_1;

5) vero che il sig. Pt_1 decise di acquistare l'appartamento oggetto della presente causa fg 376 mapp 330 sub 5 in quanto in futuro sarebbe stato poi possibile scorporare una stanza ed annetterla all'appartamento contiguo mapp 330 sub 6 dell'avv. CP_3 che doveva essere intestato al figlio Persona_3 in modo tale che questi potesse avere un appartamento delle stesse dimensioni di quello intestato alla sorella che era leggermente più grande.

6) vero che l'appartamento in Milano via Debussy n. 10 fg. 376 mapp 330 sub 4 proveniente dall'eredità materna della sig.ra Pt_2 venne intestato a favore della figlia Controparte_4 come da atto di donazione diretta di cui al doc. 17;

7) vero che venne avviata la trattativa con l'avv. CP_3 intenzionato a vendere il proprio appartamento;

8) vero che l'appartamento però rimase in proprietà dell'avv. Controparte_3 che cambiò idea sulla vendita vendendolo in seguito ad altre persone (come da doc. 17);

9) vero che l'appartamento di cui è causa – fg 376 mp 330 sub 5 venne acquistato intestandolo alla sig.ra Pt_2 per ragioni di carattere fiscale con l'intesa che sarebbe stato pagato dal sig. Pt_1

Pt_1 e che sarebbe rimasto di sua proprietà e così la famiglia *Pt_1* – *Pt_2* ha sempre vissuto nell'appartamento intestato alla figlia *Per_2* ;

10) vero che il pagamento dell'appartamento è stato effettuato mediante erogazione di mutuo sul conto corrente alimentato con denaro del sig. *Pt_1* e precisamente come da docc. 5, 6 e 7 ed attualmente il mutuo viene pagato dal sig. *Parte_1* come anche da doc. 21 ;

11) vero che l'ing. *Pt_1* ha ricevuto dal sig. *Pt_3* la somma di euro 120.000,00 di cui agli assegni emessi sub doc. 9 derivante dalla vendita del terreno di proprietà degli eredi *Pt_1* di cui al contratto 16.2.2004 sub doc. 10 versandola sul conto corrente di cui al doc. 5;

12) vero che ha poi versato le rate di mutuo alimentando il conto corrente con il proprio stipendio e proprie somme di cui al doc. 5,6,7 ed ha poi versato le ulteriori rate dal 1.01.2015 all'aprile 2016 del mutuo per euro 4038,00 come da doc. 21;

13) vero che il sig. *Pt_1* ha concesso in locazione, dall'anno 2006 fino al 2008, l'appartamento mapp 330 sub 5 al sig. *CP_5* il quale effettuava i pagamenti direttamente al sig. *Pt_1* con bonifico come indicato sugli estratti conto sub doc. 5;

14) vero che la sig.ra *Tes_1* ha rilasciato la procura generale sub doc. 20 per consentire al sig. *Pt_1* la gestione e la vendita dell'immobile sito in Milano via Debussy 10 mapp 330 sub 5;

15) vero che nel gennaio 2012 il sig. *Pt_1* ebbe a promettere in locazione ai sigg. *CP_6* [...], *Parte_4*, *Controparte_7* e *Parte_5* iniziando ad ospitarli ;

16) vero che dopo il 7.7.2012 si è verificata la separazione di fatto tra l'attore e la convenuta;

17) vero che dopo il 7.7.2012 la sig.ra *Pt_2* allontanò i conduttori sigg. *Controparte_6*, *Parte_4*, *Controparte_7* e *Parte_5* e affittò l'appartamento ad altri inquilini con regolare contratto registrato presso l'agenzia delle entrate che si sono successivamente alternati ad altri fino al 31.12.2015 incassando euro 55.350,00 ;

18) vero che la sig. *Pt_2* ha tentato la vendita dell'appartamento di via Debussy fg. 376 mapp 330 sub 5 come accertato dall'arch. *Per_4* come da docc. 10;

19) vero che dopo la citazione del 11.12.2014 la sig.ra *Pt_2* ebbe a rinunciare alla vendita come da lettera del 28.1.2015 (doc. 22-23);

20) vero che la *Pt_2* ha concesso in locazione dall'inizio del 2015 al 31.12.2015 l'appartamento di via Debussy 10 fg 376 mapp 330 sub 5 di cui al doc. 10 ai sig. *Persona_5* e ad alla sig.ra [...]

Pt_6 percependo le somme di cui al doc. 24.

Si indicano a testi: 1) avv. **Controparte_3** di Napoli su tutti i capitoli; 2) prof **Testimone_2** di Milano via Piceno 27 su tutti i capitoli; 3) sig. **Persona_3** di Milano via Debussy 10 su tutti i capitoli; 4) Direttore **Org_3** **Org_2** Filiale di Corsico su tutti i capitoli e segnatamente sui capp. da 1 a 13; 5) Direttore **Org_4** filiale di Milano c.so XXII marzo e di viale Piceno nonché i Direttori di cui alle filiali degli estratti conto prodotti sub doc. 5,6,7 e 21, su tutti i capitoli e segnatamente sui capp. da 1 a 13; 6) sig. **Controparte_6** su capp da 15 a 17 ; 7) sig, **Parte_4** su capp da 15 a 17; 8) sig. **Controparte_7** su capp da 15 a 17; 9) sig. **Parte_5** su capp da 15 a 17; 10) arch **Testimone_3** di **Tes_4** di Lainate via Ariosto su tutti i capitoli e in particolare i capp. 15, 16, 17, 18 e 19; 11) sig. **Testimone_5** di Locri sul cap. 11; 12) sig. **Persona_5** di Milano e sig.ra **Testimone_6** di Milano entrambi sul cap. 20.

Si chiede occorrendo ctu contabile per accertare le somme dovute.

Spese, diritti ed onorari.”

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** ha citato in giudizio **Parte_2** dinnanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenere, in via principale, sentenza dichiarativa di esclusiva ed effettiva proprietà dell’immobile sito in via Debussy n. 10, Milano, previo accertamento e dichiarazione che la compravendita dell’immobile *de quo* fosse stata oggetto di simulazione soggettiva o di intestazione fiduciaria. In via subordinata e/o alternativa ha esperito l’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle risorse finanziarie personali utilizzate per il pagamento delle rate del mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile.

Esponeva l’attore: a) di aver contratto matrimonio concordatario con la **Pt_2** e di aver optato per il regime della separazione dei beni; b) che in costanza di matrimonio i due coniugi avrebbero deciso di acquistare un appartamento in Milano, via Debussy 10; c) che per ragioni fiscali lo stesso sarebbe stato intestato alla sola **Pt_2** d) che contestualmente all’acquisto, i coniugi avevano acceso un mutuo ipotecario intestato ad entrambi, ma pagato esclusivamente dal **Pt_1** e da lui gestito fino al sopravvento della crisi coniugale, e dava infine atto di aver già promosso precedenti azioni nei confronti della **Pt_2** poi desistite.

Si costituiva in giudizio la **Pt_2** chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Con sentenza n. 4290/2018, pubblicata in data 16 aprile 2018, il Tribunale rigettava la domanda principale di accertamento della proprietà dell'immobile condannando la *Pt_2* alla restituzione della sua quota di spettanza del debito solidalmente assunto con il contratto di mutuo.

Avverso la sentenza di primo grado *Parte_1* ha proposto appello affidandolo a più motivi.

L'appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 15 aprile 2021.

Esaurita la fase di trattazione, precisate le conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2021, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Motivi

Cap. 1)

Con il primo motivo l'appellante si duole della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della proprietà esclusiva dell'immobile sito in via Debussy n. 10.

Il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore in sede di inquadramento giuridico del negozio intercorso tra le parti, trattando il caso di specie alla stregua di una ipotesi di simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona, ritenendo conseguentemente necessaria la prova scritta dell'accordo simulatorio ai sensi dell'art. 1414 cc.

Sostiene l'appellante che non ricorrerebbe nel caso in esame l'ipotesi di simulazione relativa soggettiva mancando la compartecipazione di tutti i contraenti della vendita, in particolare, non vi sarebbe stato alcun coinvolgimento del venditore.

A parere dell'appellante, si verterebbe nella diversa ipotesi di negozio fiduciario, affrancato dai limiti di prova scritta previsti dall'art. 1414 cc..

Il *pactum fidiciae* avrebbe potuto essere provato attraverso i documenti depositati in primo grado (dichiarazioni giudiziali rese dalla moglie in sede di separazione) aventi quanto meno valore indiziario, nonchè attraverso la prova testimoniale già richiesta.

Il motivo risulta destituito di fondamento e non merita accoglimento.

Invero, è lo stesso *Pt_1* che in via principale ha chiesto l'accertamento della simulazione dell'intestazione dell'immobile alla moglie e in alternativa l'accertamento del *pactum fiduciae*; non si comprende, dunque, in quale errore sia incorso il Giudice in primo grado.

Appare risolutivo, a tal proposito, richiamare le conclusioni che lo stesso appellante ha formulato nei suoi atti: “- *accertare e dichiarare la simulazione soggettiva ovvero la intestazione fiduciaria alla sig.ra* *Parte_2* [...] *relativamente alla compravendita immobiliare [...] avente ad oggetto l'appartamento sito in Milano via Debussy n. 10 [...]*”.

Il negozio atipico che l'appellante richiama, per la prima volta in tale sede, risulta un'allegazione generica e completamente sprovvista di qualsivoglia fondamento. Egli è ben consapevole delle limitazioni che la legge pone rispetto all'onere probatorio della simulazione tra le parti e il motivo di appello in esame pare, piuttosto, un maldestro tentativo per eludere tali limitazioni.

Ad ogni buon conto, rispetto alla prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, la Corte ritiene che non vi siano ragioni per doversi discostare dall'orientamento espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale è unanime del ritenere che: “*In tema di compravendita immobiliare, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto (salvo la perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724 c.c. n. 3) se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio simulatorio*”. (Cass. civ. n. 229507/2019)

Ebbene, poiché la simulazione relativa soggettiva allegata dal **Pt_1** riguarda un contratto (la compravendita di immobile) per cui la legge richiede la forma scritta *ad substantiam*, la prova dell'accordo simulatorio -traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato- avrebbe dovuto essere fornita mediante atto scritto, atto, in concreto, mai prodotto in giudizio.

Oltretutto, l'appellante finisce per fornire un'ulteriore argomentazione idonea a respingere la domanda; infatti, nell'atto di citazione in appello viene evidenziato come non possa parlarsi di simulazione relativa soggettiva poiché per la sua sussistenza è richiesta la compartecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del negozio giuridico. Tale compartecipazione non è mai stata oggetto di prova, così come non è mai stata oggetto di allegazione; tanto più, quindi, non può dirsi provata la simulazione soggettiva.

Cap. 2)

Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, ricostruendo la fattispecie alla stregua del negozio fiduciario, ed assimilando quest'ultimo al contratto preliminare (art. 1351 c.c.), esclude che anche in tal caso sia stata fornita la prova scritta necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda.

Richiama a tal proposito la recente sentenza della Suprema Corte (SS. UU. Sent. n. 6459/2020) secondo la quale *“Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.”*

Il *pactum fiduciae*, così qualificato, configura un mandato senza rappresentanza, con effetti meramente obbligatori che impongono al mandatario/fiduciario il trasferimento dell'immobile al mandante/fiduciante o ad un terzo da lui indicato, onde l'esistenza di tale accordo resta sottratta al limite della prova scritta. Conseguentemente l'appellante insiste per l'ammissione delle istanze

istruttorie orali già formulate in primo grado, idonee a suo dire a fornire la prova dell'intervenuto negozio.

Il motivo è infondato e non merita accoglimento.

Rileva la Corte, che la richiamata sentenza a Sezioni Unite puntualizza che: *“Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum”*.

Il nuovo orientamento, di segno opposto a quello fatto proprio dal Giudice di prime cure (vedi pag. 11 sentenza n. 4290/2018 in cui Tribunale di Milano ha statuito che: *“in mancanza di una pattuizione scritta con cui il fiduciario si obbliga a gestire il bene e a ritrasferire la proprietà in capo al fiduciante, il pactum fiduciae non può dirsi provato [...] essendo la forma scritta richiesta ad substantiam.”*), rende necessaria una più attenta valutazione delle prove offerte e dei mezzi di prova richiesti dal **Pt_1** già nell'ambito del primo grado.

Il Tribunale ha statuito che *“anche laddove volesse prendersi in considerazione l'astratta prospettiva fiduciaria, si perverrebbe comunque al rigetto della domanda attorea, atteso che le allegazioni della parte al riguardo risultano ancora una volta sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio”*.

L'appellante argomenta che la prova dell'accordo fiduciario possa essere desunta dal materiale probatorio allegato e rafforzata dalla prova testimoniale articolata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

Quanto ai documenti essi consistono:

- 1) nel ricorso per separazione (doc. 13 fascicolo primo grado), nel quale verrebbe in rilievo la seguente asserzione: *“La signora **Pt_2** intestataria formalmente di altro appartamento sempre in Milano, Via Debussy n. 10 di cui il sig. **Pt_1** percepisce canone di locazione brevi manu, canone che ammonta a circa € 1.000,00 mensili [...]”*;
- 2) nella dichiarazione fornita dalla **Pt_2** nel verbale della causa R.G. n. 78196/2014 (doc. 14 fascicolo primo grado) dal seguente tenore: *“Il mutuo della casa a me intestata, sino ad oggi è stato totalmente pagato dal **Pt_1** [...]”*;

- 3) nella deposizione testimoniale resa da **Persona_3** (figlio dei coniugi) nell'ambito di un procedimento penale nella quale si legge: *“L'appartamento è di proprietà di mio padre perché i soldi con il quale è stato pagato l'anticipo, la caparra diciamo, più il mutuo che comunque sta pagando lui, derivano da soldi... cioè l'ha pagato lui con i soldi della madre, eredità.”* (doc. 15 fascicolo primo grado).

Tali documenti provano che i mezzi di pagamento sono stati forniti dal **Pt_1**, ma non anche un obbligo giuridico di trasferimento dell'immobile dalla **Pt_2** al marito, potendo la fattispecie essere diversamente inquadrata (ad es. donazione indiretta). Quanto al doc. 13, in particolare, non si ritiene che esso abbia natura confessoria: la dichiarazione della **Pt_2** di essere “intestataria formale” è asserzione contenuta in un atto difensivo nel giudizio di separazione personale.

Secondo il principio affermato dalla Suprema Corte *“Il giudice civile può trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, C.P.C., da un documento proveniente dal difensore, formato in altro giudizio, in rapporto al comportamento processuale della parte che non ne abbia contestato il contenuto; tale comportamento, tuttavia, non può essere posto da solo a fondamento della decisione, ma deve essere valutato insieme all'intero materiale probatorio acquisito al processo, alla stregua dei parametri indicati nell'art. 2729 c.c.”* (Cass. civ. n. 10650/2008). Facendo corretta applicazione della suddetta regola l'affermazione difensiva della **Pt_2** di essere “intestataria formale”, in quanto contestata nel merito, non può valere come confessione e comunque non è probante quanto all'esistenza di un obbligo fiduciario di trasferimento del bene in capo al marito.

Da ultimo, ma non ultimi per importanza, ad escludere l'esistenza di un *pactum fiduciae*, per una diversa concordata destinazione dell'immobile sono gli stessi argomenti del **Pt_1** laddove afferma (pag. 12 appello, cpv. 2) che tale appartamento era destinato al figlio **Per_3** per assicurargli lo stesso trattamento della sorella *“che aveva ricevuto altro appartamento sullo stesso pianerottolo con i proventi dell'eredità **Pt_2**”*. Per **Per_3** l'appartamento sarebbe stato acquistato con i proventi del padre, ed avrebbe avuto ad oggetto un terzo appartamento sul piano. Questo per cui è causa era stato nel frattempo acquistato (intestato alla madre) con l'intenzione di scorporare una parte per annetterlo a quello che in futuro sarebbe stato di **Per_3**.

Come si vede detto programma familiare finalizzato alla equa sistemazione dei figli della coppia, esclude ex se che fosse intervenuto tra le parti un patto fiduciario con obbligo di trasferimento del bene al **Pt_1**.

Quanto alle prove orali.

I capitoli di prova allegati da **Pt_1** sul punto (da 1 a 9, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) non sono idonei a fornire la prova dell'esistenza di un accordo fiduciario verbale: il capitolo 1 è generico ed irrilevante; i capitoli 2, 3, 4, 5 sono irrilevanti ai fini della decisione; il capitolo 6 verte su circostanze documentali; i capitoli 7 e 8 sono irrilevanti ai fini della decisione; il capitolo 9 è generico, valutativo ed irrilevante.

Cap. 3)

Con il terzo motivo di appello il **Pt_1** lamenta l'errata applicazione dell'art. 219 c.c.; in particolare, il Giudice di prime cure, riconoscendo che l'articolo da ultimo citato trova applicazione nelle controversie relative ai soli beni mobili, lo avrebbe interpretato in modo errato. Dunque, in applicazione dell'art. 219 c.c., viene chiesto il riconoscimento della proprietà di almeno il 50% dell'immobile oggetto del giudizio.

Il motivo è infondato e non merita accoglimento.

La Corte di Cassazione, ha stabilito che: “[...] *quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d'acquisto, l'altro coniuge, che allegghi l'interposizione reale, non può provarla con giuramento, né con testimoni, giacché l'obbligo dell'interposto di ritrasmettere all'interponente i diritti acquistati deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento e non anche, dunque, nel caso in cui si deduce un semplice principio di prova per iscritto*” (Cass. sez. I, n. 18544/2013).

Anche se tale principio può ritenersi superato alla luce della già richiamata sentenza delle SS.UU. 6459/2020, in quanto l'interposizione reale di persona, avente ad oggetto un bene immobile, non deve necessariamente avere forma scritta *ad substantiam*; nel caso di specie tale prova non è stata fornita.

Il secondo comma dell'art. 219 c.c. prevede, poi, che: “*I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi*”.

Nel caso che ci occupa la **Pt_2** può dimostrare la proprietà esclusiva dell'immobile di via Debussy 10 in forza di regolare contratto di compravendita stipulato in data 23 ottobre 2003.

Cap. 4)

Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'appellata sentenza nella parte in cui viene riconosciuta applicabile, al caso di specie, la disciplina della solidarietà passiva delle obbligazioni e dell'art. 1298 c.c. per quanto attiene ai rapporti interni tra i debitori solidali. Sostiene che si tratterebbe di solidarietà passiva con interesse esclusivo di una sola parte e non di solidarietà passiva con interesse plurisoggettivo come rilevato nel giudizio di primo grado. Il Giudice di prime cure avrebbe confuso la nozione di interesse con la nozione di motivi e sarebbe giunto ad una ricostruzione errata. L'interesse all'adempimento dell'obbligazione di pagare il mutuo sarebbe esclusivamente della **Pt_2** con conseguente richiesta di condanna di quest'ultima al pagamento dell'intero importo e non al solo 50%.

Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

La disciplina dettata dagli articoli 1298 e 1299 c.c. consente di affermare l'esclusiva rilevanza esterna del vincolo solidale, il quale rimane, invece, del tutto neutro rispetto al concreto atteggiarsi del rapporto interno tra condebitori. Sono, pertanto, compatibili con la solidarietà sia le obbligazioni plurisoggettive ad interesse comune che quelle nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori.

L'assetto interno dell'obbligazione ad attuazione solidale è normalmente determinato dalla causa dell'obbligazione, individuata con riferimento al momento genetico dell'atto.

E' necessario esaminare quale sia stata la causa dell'obbligazione al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo. Il mutuo è stato contratto ed erogato per far fronte alla spesa per l'acquisto della proprietà dell'immobile sito in Milano, via Debussy 10; a sostegno di ciò è opportuno mettere in evidenza che il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato contestualmente al contratto di compravendita, in forza del quale la **Pt_2** è divenuta esclusiva proprietaria dell'immobile -in data 27 ottobre 2003.

Nel caso concreto, al di fuori dei motivi che hanno spinto le parti ad accendere il mutuo -e che sono irrilevanti-, può dirsi esistente un accordo tra i coniugi che li ha indotti ad assumere in maniera solidale l'obbligazione di pagare il mutuo. L'accordo sottostante è da individuare nell'acquisto dell'immobile

per il successivo trasferimento dello stesso al figlio della coppia, in modo tale da garantirgli un immobile al pari di quanto fatto con l'altra figlia della coppia. Dunque, nel momento in cui l'obbligazione di pagare il mutuo è sorta può dirsi che, anche nei rapporti interni, l'obbligazione era stata assunta dai coniugi nell'interesse comune e non nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Tuttavia, l'assetto interno dell'obbligazione solidale non è immutabile ma, durante lo svolgimento del rapporto e fino al momento estintivo, può essere modificato per effetto di convenzioni tra i soggetti tenuti volte a spostare l'originario peso del debito nei rapporti interni, oppure per effetto di alterazioni funzionali dell'originario assetto causale verificatosi sempre nel corso del rapporto.

Nel caso che ci occupa può dirsi che sia accaduto proprio quanto da ultimo esposto, e cioè il verificarsi, nel corso dello svolgimento del rapporto, di un'alterazione funzionale dell'originario assetto dei rapporti interni. Infatti, non essendo stato realizzato quanto originariamente previsto, cioè il trasferimento dell'immobile acquistato al figlio della coppia, i rapporti interni hanno subito una modificazione in forza della quale l'interesse non può più dirsi comune, ma esclusivo del coniuge che ha acquistato la proprietà dell'immobile de quo. Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità, in una vicenda in cui l'assetto interno dell'obbligazione è mutato per effetto di alterazione funzionale dell'originario assetto causale, si è espressa in tal senso: *“Nell'ipotesi in cui i coniugi contraggano insieme un mutuo ipotecario per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale, ma successivamente tale somma venga utilizzata esclusivamente dal marito per motivi professionali, la moglie è legittimata al regresso per l'intero importo indebitamente sostenuto nell'interesse esclusivo dell'uomo. Infatti, anche se l'obbligazione di restituire in solido l'importo mutuato dai coniugi risulta assunta nell'interesse di entrambi e non soltanto di uno dei coniugi, ciò non è sufficiente per invocare la ripartizione del debito ex artt. 1298 e 1299 c.c., atteso che tale regola non opera quando l'obbligazione solidale viene meno per vizio funzionale della causa che ha portato all'accordo”*. (cfr. Cass. civ. n. 24389 del 1° dicembre 2010)

Considerato che l'interesse non è identificabile nell'interesse psicologico dei debitori, e cioè nel motivo che li spinge ad obbligarsi ma, piuttosto, con la controprestazione o il godimento del bene, ne consegue che l'interesse dei debitori è un interesse in senso oggettivo, ravvisabile nel vantaggio derivante dall'obbligazione (cioè dalla controprestazione). Nel caso di specie dell'obbligazione assunta dai coniugi solidalmente avrebbe dovuto beneficiare il figlio, ma, con il venir meno dell'accordo, della

controprestazione ottenuta grazie all'assunzione dell'obbligazione è divenuta esclusiva titolare, in concreto, la Pt_2

In definitiva, l'affare per il quale fu contratto il debito è stato originariamente concluso nell'interesse di entrambi i coniugi, in forza dell'accordo volto a trasferire la proprietà del bene al figlio, ma è intervenuta un'alterazione funzionale dell'originario assetto causale nel momento stesso in cui l'unica destinataria della controprestazione è divenuta la Pt_2

Versando in un'ipotesi di obbligazione solidale ad interesse monosoggettivo, trovano applicazione regole parzialmente diverse rispetto a quelle applicabili alle obbligazioni solidali con interesse comune. Per ciò che in tale sede interessa, obbligazioni di questo tipo comportano l'attribuzione all'adempiente, che sia debitore "senza interesse", dell'azione recuperatoria per l'intera prestazione eseguita contro l'unico interessato. Alla luce di quanto precede, può essere accolta la domanda del Pt_1 -quale debitore senza interesse- volta alla restituzione dell'intera prestazione eseguita dell'interesse esclusivo della Pt_2 sulla quale dovrà gravare il peso dell'intero debito.

L'accoglimento del quarto motivo rende superfluo l'esame degli altri rimasti (5° e 6°)

Per tali ragioni va accolto l'appello con condanna dell'appellata Pt_2 alla restituzione, in via di regresso, dell'intera somma pagata dal Pt_1 in forza del contratto di mutuo n. 08/61762462.

L'appellante chiede la conferma del rigetto delle eccezioni di controparte come stabilito dal Tribunale.

La conferma è la naturale conseguenza della mancata costituzione dell'appellante che evidentemente nessuna eccezione ha riproposto in questo grado, onde la sentenza sul punto deve ritenersi passata in giudicato.

La parziale riforma della sentenza comporta un nuovo regolamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio; esse sono poste a carico dell'appellata Pt_2 e liquidate come segue secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, riforma dell'appellata sentenza n. 4290/2018 del Tribunale di Milano, così dispone:

-accertato che *Parte_1* è creditore, in via di regresso, della somma di € 220.739,75, pari all'intera somma corrisposta dallo stesso in forza del contratto di mutuo cointestato con interesse esclusivo della *Pt_2*

-conferma nel resto al sentenza gravata;

-condanna l'appellata *Parte_2* a restituire all'appellante, *Parte_1* [...], la somma di € 220.739,75, oltre le rate maturate dal luglio dal luglio 2015 oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo;

-condanna *Parte_2* a rifondere a *Pt_1*, le spese legali del primo grado liquidate in €. 12.000,00 oltre il 15% per spese generali e accessori di legge;

-condanna *Parte_2* a rifondere a *Pt_1*, le spese legali del primo grado liquidate in €. 12.000,00 oltre il 15% per spese generali e accessori di legge;

Così deciso in Milano il 16/03/2022

Il Presidente est.

dott. Marina Marchetti

